

1111819-18.2020.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... como importante instrumento de facilitação do tráfico jurídico.

A relevância dessas características é notada quando o título entra em circulação e o crédito cartular é feito valer pelo portador, que é terceiro na relação subjacente.

Enquanto o título permanece em mãos do primeiro tomador, tais características, especialmente a autonomia, não alcançam relevo. É que, figurando como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

5ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1111819-18.2020.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1111819-18.2020.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente e Reconvinte:

Anna Luiza Ramos Fonseca e outro

Reconvindo e Requerido:

Anna Luiza Ramos Fonseca e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

ANNA LUIZA RAMOS FONSECA, qualificada nos autos, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c sustação de protesto e danos morais contra FRANCISCO RODRIGUES LOPES - MOVEIS e outro, igualmente qualificado, aduzindo, em síntese, que celebrou contrato com a parte ré para serviços de marcenaria, porém, o requerido iniciou o trabalho e não o concluiu. Alega que depositou a entrada do pagamento e entregou os cheques para pagamento das demais parcelas, que após ter excedido mais de 30 dias depois do prazo e incessantes tentativas de contato, o réu não cumpriu com o acordo, portanto, sustou os pagamentos posteriores. Relata que houve o protesto dos cheques realizado pelo outro réu, cuja relação comercial com a autora é inexistente. Requer a procedência da demanda que consiste na concessão da tutela antecipada, a qual declara inexistência do débito e resolução do contrato. Requer o pagamento da repetição do indébito no valor de R\$ 10.000,00 e danos morais. Juntou documentos (fls. 20/48).

Regularmente citado, o réu JOSE DI NIZO ofereceu contestação às fls. 63/38, arguindo preliminarmente, a impugnação ao valor atribuído à ação e a

inaplicabilidade do CDC. No mérito, defendeu que o contestante é terceiro de boa-fé e que não teve relação comercial com a autora. Pugnou pela improcedência da demanda.

Réplica às fls. 79/82.

Em especificação de provas, o requerido JOSE DI NIZO pleiteou prova documental e oitiva de testemunhas, enquanto a requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Citado, o réu FRANCISCO RODRIGUES LOPES - MÓVEIS apresentou contestação e reconvenção (fls.117/132). Em preliminar, alegou a tempestividade. No mérito, alegou o não cabimento da inversão do ônus da prova, a prescrição do dano moral, a não comprovação de desacordo comercial, que o autor não carreteou provas da não entrega dos móveis e reforma dos existentes. Pugnou pela improcedência da demanda. Em reconvenção, requer o deferimento do pedido do pagamento de R\$ 6.072,18 referentes aos cheques sustados.

O autor-reconvindo apresentou contestação à reconvenção (fls. 147/158).

O autor-reconvindo requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto o réu-reconvinte pleiteou a realização de audiência de instrução para produção de prova testemunhal.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, defiro os benefícios da gratuidade ao requerido. Anote-se.

I - DA AÇÃO PRINCIPAL

Julgo o processo no estado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discricção do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório." (STJ, 4ª Turma, REsp 3.047-ES, Rel. Min. Athos Carneiro, julgado em 21.08.90, DJU 17.09.90, p. 9.514). Indefiro o pedido do réu para oitiva de testemunhas. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa. Além disso, o pedido é genérico, não demonstrando a parte como os depoimentos poderiam influenciar no julgamento da demanda.

Rejeito a impugnação ao valor da causa, uma vez que a autora considerou os valores dos danos morais (R\$ 10.045,00) e da repetição de indébito em dobro (R\$ 10.000,00). Aplicável, na hipótese sub judice, o Código de Defesa do Consumidor. De um lado, a requerente constitui-se consumidora, haja vista o artigo 2º, caput, do diploma legal, porquanto destinatária final do bem. De outro, o(s) requerido(s) enquadra-se na definição legal de fornecedor de seu artigo 3º, caput, uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens no mercado de consumo. Configurada a relação de consumo, o diploma consumerista é de aplicação imperativa.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

A demanda é parcialmente procedente.

Em relação ao requerido JOSÉ DI NIZO, cabe salientar que segundo o art. 25 da Lei do Cheque (7.357, de 2.9.85), "Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor".

O cheque constitui título cambial dotado das características de literalidade, autonomia e abstração.

A abstração significa que o crédito consubstancia-se no título, independentemente de qual tenha sido a sua causa, ou seja, tratando-se de ordem de pagamento à vista, vale pelo que nele está escrito, independentemente a sua cobrança de investigação da relação jurídica subjacente.

A autonomia, que mais importa na presente análise, indica a independência da posição do possuidor atual do título em relação à posição de cada um dos possuidores antecedentes.

Isso implica a inoponibilidade de exceção pessoal do devedor ou obrigado ao credor que, de boa-fé, detenha o título. Este é terceiro em relação aos participantes dos negócios anteriores, ou seja, aquele negócio que gerou o título e aqueles negócios que implicaram sua circulação.

As três características decorrem da necessidade de se atribuir segurança e certeza ao título, assim que formado e durante a sua circulação, servindo ele como importante instrumento de facilitação do tráfico jurídico.

A relevância dessas características é notada quando o título entra em circulação e o crédito cartular é feito valer pelo portador, que é terceiro na relação subjacente.

Enquanto o título permanece em mãos do primeiro tomador, tais características, especialmente a autonomia, não alcançam relevo. É que, figurando como parte da relação jurídica subjacente, o portador tem, no título, o mesmo direito que decorre dessa relação, por isto lhe podendo ser oposta, pelo devedor, todas as exceções, inclusive as pessoais e referentes a esse negócio basilar.

Na situação presente, restou incontroverso que a autora emitiu os cheques nº 298807, 298808 e 298809, cada um no valor de R\$ 1.000,00 com vencimento em 23/06/2016; 23/06/2017 e 23/06/2018 (fls.22/24).

Nesse contexto, denota-se que o cheque circulou bem antes da contraordem de pagamento, realizada somente 27/06/2017 (fls.26), não havendo qualquer início de prova a demonstrar que o réu obteve a cártula de má-fé, consciente da inexistência da dívida nele consubstanciada essa, aliás, é a única matéria pertinente nesta demanda que estabeleceria um vínculo entre a autora, emitente, e o atual tomador. Não se pode olvidar, como dito, que o cheque ao portador pode circular livremente, indo para mãos de terceiro, independentemente, inclusive, de endosso. Nesse sentido:

“BANCÁRIO Cheques objeto de contrato de desconto e apresentados a protesto por falta de pagamento Cheque é ordem de pagamento à vista Banco na posição de endossatário é terceiro de boa-fé na ausência de provas de recebimento dos cheques com conhecimento do malogro do negócio entre emitente e endossante Inoponibilidade das exceções pessoais Aplicação da Lei número 7.357/85, artigos 32 e 25 Apresentação à agência sacada e a protesto caracterizam exercício regular de direito (CC, artigo 188, I) Ação anulatória julgada improcedente Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do RITJSP, artigo 252 Negado provimento ao recurso.x (...) embora frustrado o negócio, a obrigação cambial manteve-se intacta por força da autonomia da relação cambiária. O banco é terceiro de boa-fé. Recebeu os cheques por endosso translativo. Os títulos circularam regularmente e sua validade e eficácia independem do negócio jurídico subjacente à sua emissão. O desfazimento da venda de que resultou a emissão não conduz à nulidade ou à inexigibilidade dos cheques em poder do terceiro de boa-fé, inteiramente alheio ao negócio causal. Contra o terceiro de boa-fé não podem ser opostas exceções pessoais, por conta da autonomia da relação cambial que resulta do endosso. Por certo, o desfazimento do negócio em que o banco não foi parte é modalidade de exceção pessoal, que a autora só pode opor perante a ré vendedora. Endosso não é cessão. O endossatário sucede o endossante na posse do título que lhe é transmitido. Mas não o sucede na relação jurídica existente entre o devedor e o endossante (JOÃO EUNÁPIO BORGES, Títulos de Crédito, 1ª ed. Forense, pág. 74). O endosso constitui relação cambiária autônoma. E o cheque, como ordem incondicional de pagamento à vista, é título literal e abstrato. Circulando regularmente, outorga ao legítimo portador direito de crédito cuja realização não é afetada por questões vinculadas ao negócio causal. (...) “O cheque é título literal e abstrato. Exceções pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente podem ser opostas a quem tenha participado do negócio. Endossado o cheque ao terceiro de boa-fé, questões ligadas à causa debendi originária não podem ser manifestadas contra terceiro legítimo portador do título” (JSTJ, 17/142; RT 661/188). Dessa forma, o banco se tornou titular do crédito por força de operação de desconto e, ao não vê-lo compensado, agiu no exercício regular do seu direito, os encaminhando a protesto, até porque os adquiriu de boa-fé (TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado D, Apel. nº 0002154-94.2010.8.26.0404, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 28.07.15). Ausente, no caso, prova de que o cheque foi repassado ao réu, estando ele ciente do desacordo comercial, , afasta-se qualquer pretensão à indenização por dano moral ou material.

No que tange ao réu FRANCISCO RODRIGUES LOPES - MÓVEIS, não obstante o princípio

pacta sunt servanda, a conferir a natureza ao contrato de “lei entre as partes”, sofrer, no moderno direito obrigacional, relativização, notadamente por normas de ordem pública e, por consequência, de caráter cogente, como as aplicáveis às relações de consumo, a força vinculante do pacto prevalece, devendo ser cumpridas as respectivas obrigações (cf. STJ, Resp 167.978/PR, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, SEXTA TURMA, julgado em 26.05.1998, DJ 22.06.1998 p. 213). Cumpre anotar, ainda, segundo ensina Antônio Junqueira de Azevedo, que “a declaração de vontade, tomada primeiramente como um todo, deverá ser: a) resultante de um processo volitivo; b) querida com plena consciência da realidade; c) escolhida com liberdade; d) deliberada sem má-fé” (Negócio Jurídico - Existência, Validade e Eficácia, 4a ed., São Paulo: 2002, p. 43).

Os contratos são estabelecidos entre as partes, buscando a satisfação de seus interesses. Geram, para cada um dos contratantes, direitos e obrigações. Caso uma das partes que entabulou a avença, ao passo que pode exigir a contraprestação respectiva, deve, necessariamente, cumprir com seus deveres, segundo o pactuado. Na hipótese de inadimplemento da prestação devida por um dos contratantes, surge ao outro a possibilidade de pleitear a resolução do negócio jurídico (cf. Orlando Gomes, Contratos, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 176). Em todo o contrato bilateral, inexorável a existência, consoante o artigo 475 do Código Civil, de cláusula resolutiva tácita, facultando a resolução da avença, na hipótese de inexecução (cf. Orlando Gomes, Contratos, Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 173). Superado esse ponto, depara-se com o tema da prescrição, pretendendo o réu o reconhecimento do prazo trienal para cobrança dos danos morais, nos termos do artigo 206 do Código Civil.

A presente ação objetiva a declaração de inexigibilidade dos cheques emitidos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

O fato danoso a considerar é a realização do protesto, de iniciativa de terceiro de boa-fé, visando o recebimento dos cheques, de que se tornou titular. A emissão da cártula faz surgir uma relação jurídica diversa (cambial), e a transmissão por endosso confere ao endossatário a propriedade do título, sem vinculá-lo ao negócio jurídico subjacente.

O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil; e é contado a partir do momento em que a autora tomou conhecimento acerca do protesto, e não da data do vencimento do título ou do protesto, propriamente dito.

Na hipótese, a despeito do título ter sido registrado em 27/06/2017 e da Lei nº 9.492/1997, em seu artigo 14, determinar expressamente ao Tabelião de Protesto a expedição de “intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante”, após o protocolo, o documento de fls.27/28 evidencia que a autora foi cientificada somente em 23/10/2020, oportunidade em que realizada pesquisa de negativação em seu nome, nexistindo nos autos prova de que a ciência inequívoca do ato tenha ocorrido anteriormente. Assim, rejeito a alegação de prescrição.

Destarte, o princípio da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil dispõe que, existentes obrigações complementares entre as partes de um contrato, caso a primeira descumpra sua parte, a segunda poderá negar-se ao cumprimento da sua obrigação, até que ela aquela adimpla com dever pactuado. É o entendimento do E.TJSP:

CONTRATO - Depósito - Ação de indenização cumulada com rescisão contratual - Exceção de contrato não cumprido - Cabimento - Descumprimento de cláusula contratual pela prestadora de serviço comprovado - Inexigibilidade de pagamento cabível - Contrato rescindido - Recurso desprovido - Sentença mantida. (TJ-SP - AC: 00163351320078260564 SP 0016335-13.2007.8.26.0564, Relator: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 05/05/2010, 21ª Câmara de Direito Privado).

AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - CABIMENTO - Contrato de compra e venda de quotas sociais que previa a obrigação do autor, ora apelante e alienante das quotas, de quitar todas as dívidas preexistentes à assinatura do instrumento, entregando o estabelecimento

livre e desembaraçado de quaisquer ônus – Autor que alega que a obrigação de pagamento preexistia à obrigação de quitação das dívidas, não podendo tal cláusula ser utilizada para que os réus se esquivem da obrigação – Interpretação sistemática das cláusulas contratuais que permite concluir que a obrigação de quitação das dívidas e entrega do estabelecimento livre e desembaraçado é imediata e contemporânea à assinatura do instrumento, o que não ocorreu – Dívidas, ademais, que sequer foram negadas pelo autor apelante – Incidência, no caso, da "exceção de contrato não cumprido" (art. 476, Código Civil)- Sentença de improcedência da ação monitória mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10005744020158260629 SP 1000574-40.2015.8.26.0629, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 04/04/2014, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 31/01/2020). Dessa forma, diferente do que afirma o requerido, não cabe à autora comprovar que não houve a efetiva prestação do serviço, mas a ele comprovar que entregou os móveis, ainda que a destempo.

Na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova. Atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático. Segundo os ensinamentos de Francesco Carnelutti e Humberto Theodoro Junior acerca do ônus da prova:

(...) como quem tem interesse em afirmar um fato tem interesse também em obter e, especificamente, em preconstituir a sua prova quando esta não é exibida, isso quer dizer que o fato não existiu. Assim, quando se não exhibe a quitação, há que concluir que o devedor não pagou. O princípio exposto traduz-se no chamado ônus da prova. Com efeito a produção da prova de um fato torna-se ônus para a parte que tem interesse na sua afirmação" (Francesco Carnelutti, Teoria Geral do Direito, trad. Antonio Carlos Ferreira, São Paulo: Lejus, 1999, p. 541).

(...) consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não prova é o mesmo que fato inexistente" (Humberto Theodoro Junior Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281).

No mais, em conformidade ao artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil, distribuindo o ônus da prova entre as partes, cabe ao demandante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao demandado a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do ex adverso (cf., Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p. 72/74). Imperiosa, em consequência, é a resolução do contrato, diante do inadimplemento do réu, o que afasta a exigibilidade do pagamento das demais parcelas. Todavia, em relação à repetição de indébito, a autora afirmou que o réu iniciou o trabalho de manutenção dos armários, mas não o concluiu. Dessa forma, determinar a devolução dos valores quitados acarretará o enriquecimento sem causa da requerente, uma vez que houve a parcial prestação do serviço. Nesse ponto, indefiro o pedido. No que tange aos danos morais, urge a consideração, pois, que a responsabilidade civil exige para o surgimento do dever de indenizar, em sua modalidade objetiva, um dano imputado causalmente ao serviço, colocando-se o risco como nexo de imputação em coexistência com a culpa, em nosso ordenamento (cf. GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26). Na hipótese sub judice, todos os seus pressupostos restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação da demandada a indenizar os danos morais experimentados pela demandante, que além de não ter o serviço realizado a contento e de forma integral, ainda sofreu com a negativação indevida do nome por culpa do requerido.

A fixação da reparação devida, no entanto, exige razoabilidade, "evitando-se excesso que cause enriquecimento sem causa, por sua incompatibilidade com a lesão

sofrida" (cf. STJ, REsp 754.806/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 09.05.2006, DJ 26.06.2006 p. 166). Com efeito, portanto, considerando o grau de culpa e a capacidade financeira do réu, sem olvidar do aspecto compensatório, fixo o valor da reparação dos danos morais em R\$5.000,00.

II - DA RECONVENÇÃO

Julgo o processo no estado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discricção do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório." (STJ, 4ª Turma, REsp 3.047-ES, Rel. Min. Athos Carneiro, julgado em 21.08.90, DJU 17.09.90, p. 9.514). No mais, considerando que não houve a comprovação da realização do serviço, bem como entrega dos móveis, não há que se falar em pagamento do valor devido (R\$ 6.072,18).

Como restou decidido, o ônus probatório cabia ao réu, que não demonstrou, seja através de fotos, do contrato assinado, da compra de materiais a realização do serviços de marcenaria. Dessa forma, a improcedência da reconvenção é medida que se impõe.

Para os fins do artigo 489, §1º, IV, do CPC, não há outros argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por esta julgadora, e que não tenha sido considerados e devidamente valorados.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO PRINCIPAL em relação ao réu JOSE DI NIZO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO PRINCIPAL para declarar a resolução do contrato entabulado entre as partes e a inexistência do débito com o consequente cancelamento dos protestos realizados e para condenar o requerido FRANCISCO RODRIGUES LOPES - MÓVEIS ao pagamento dos danos morais no valor de R\$ 5.000,00, atualizados desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação, confirmando a tutela anteriormente deferida.

Expeça-se ofício ao 3º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo para que proceda ao cancelamento dos protestos existentes em nome da autora, ANNA LUIZA RAMOS FONSECA, referentes aos cheques nº 298807, 298808 e 298809, independente do recolhimento de custas e emolumentos. Segue a presente decisão como ofício, a ser encaminhado pela parte interessada.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 25% para a autora e 75% para o réu, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

E por fim, JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa (reconvenção).

Nada requerido, arquivem-se os autos.

P.I.C

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA